

1502904-09.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHARLES MARQUES DIONISIO e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

CHARLES MARQUES DIONISIO e ODAIR APARECIDO PAVAN JUNIOR, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502904-09.2021.8.26.0510 -
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502904-09.2021.8.26.0510 - 2021/000602

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHARLES MARQUES DIONISIO e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

CHARLES MARQUES DIONISIO e ODAIR APARECIDO PAVAN JUNIOR, qualificados no inquérito, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, assim porque, no dia 07 de setembro de 2021, por volta das 22:30 horas, na Rua 7, nº 243, Jardim Guanabara II, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, traziam consigo 90 (noventa) microtubos do tipo eppendorf contendo a substância entorpecente denominada cocaína, 07 (sete) invólucros contendo a substância entorpecente denominada tetrahydrocannabinol, e ainda guardavam e tinham em depósito, agindo em concurso e com identidade de propósitos, 54 (cinquenta e quatro) invólucros contendo aquela mesma substância entorpecente denominada tetrahydrocannabinol, totalizando com aqueles outros peso líquido aproximado de 69,4 gramas, 01 (um) invólucro plástico encerrando porção de material sólido particulado positivado para cocaína, totalizando peso líquido aproximado de 142,3 gramas, e 07 (sete) invólucros contendo cocaína, na forma de crack, totalizando peso líquido aproximado de 1,3 gramas, e, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, possuíam e mantinham sob guarda uma garrucha marca Rossi, calibre 32, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Regularmente notificados, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor dos acusados, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 26 de janeiro de 2022. Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, três testemunhas de defesa, com posterior interrogatórios dos acusados.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a parcial procedência da ação penal, assim para condenar os acusados pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fixação das penas-bases nos mínimos legais, inviabilizando-se a aplicação do redutor previsto no §4º, daquele dispositivo, seja em razão da recidiva ostentada pelo acusado Charles, seja pela dedicação ao comércio ilícito por parte de ambos, devendo as penas resultantes ser cumpridas em regime prisional inicial fechado, condenando-se, por fim, tão somente o acusado Odaír pela prática do delito previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03.

Já a ilustre Defensora inicialmente sustentou atípica a conduta no que diz com a imputação da prática do delito previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, assim por ineficácia da arma apreendida, conforme indicado no laudo pericial encartado às fls. 167/170, a determinar a absolvição, nos termos do disposto no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. De outra parte, ponderando insuficiente a prova produzida, relativamente à imputação da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, requereu a absolvição dos acusados, aqui nos termos do artigo 386, inciso VII, do mesmo Estatuto Processual Penal. Subsidiariamente, em caso de acolhimento da pretensão acusatória, requereu sejam as penas-bases fixadas no mínimo legal, incidindo a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a ambos os acusados, não obstante a recidiva de um deles, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime prisional diverso do fechado.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede em parte a pretensão acusatória.

Atribui-se aos acusados a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, assim porque traziam consigo e ainda guardavam e tinham em depósito, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, os entorpecentes indicados na denúncia e, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, possuíam e mantinham sob guarda uma garrucha marca Rossi, calibre 32, de uso permitido, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conquanto incontroversa, a materialidade dos delitos vem comprovadas pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado às fls. 160/162, com resultado positivo para cocaína, identificando-se também em parte da substância apreendida o elemento tetrahydrocannabinol, responsável pelos efeitos estupefacientes da maconha, como também positivado no laudo pericial de fls. 167/170 que a arma de

fogo apreendida, conquanto antiga, estava parcialmente operante, podendo, ainda assim ser eficazmente utilizada com a realização de disparos.

Controverte-se sobre posse da arma e do entorpecente apreendidos.

Ouvido em Juízo, o acusado Charles Marques afirmou que na ocasião estava no interior do imóvel localizado na rua 7, Jardim Guanabara, nesta Comarca, acompanhado de seu sobrinho, o acusado Odair Aparecido, realizando um reparo no local de uma torneira, quando foram abordados por policiais militares. Acrescentou que os referidos policiais realizaram uma busca no interior da moradia, por lá sendo apreendida tão somente uma garrucha antiga que pertencia ao seu pai, já falecido, com observação o imóvel se encontrava desabitado. Esclareceu que, com a chegada dos policiais, não empreenderam fuga e nenhum entorpecente foi encontrado no interior daquele imóvel, confirmando, por fim, ser reincidente pela prática de tráfico de entorpecentes.

O acusado Odair Aparecido, a sua vez, confirmou que se encontrou no imóvel acima referido com o seu tio, o acusado Charles Marques, com o propósito de realizar um reparo em uma torneira que apresentava vazamento. Neste local, foram abordados por policiais militares, que apreenderam no interior daquele imóvel tão somente uma garrucha, pertencente ao seu avô, que morava naquele local, atualmente desabitado. Igualmente negou que tivessem empreendido fuga e que tenha sido apreendido entorpecente no imóvel.

Todavia, a versão deduzida pelos acusados foi contrariada pela prova produzida. De fato, os Policiais Militares ouvidos em juízo, reiterando o que exposto contemporaneamente aos fatos, afirmaram que na ocasião estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Guanabara e, em local conhecido como ponto de venda de entorpecente, avistaram os dois acusados conversando na via pública, defronte a uma moradia. Ao notarem a aproximação da guarnição, ambos empreenderam fuga, correndo para o interior do imóvel citado, não sem antes ter o acusado Odair jogado ao chão algumas porções de maconha. Diante disto, iniciaram acompanhamento, notando que os acusados correram para os fundos daquele prédio, escalando o muro, um deles alcançando o telhado de uma residência lindeira e o outro ganhando a via pública. Acrescentou um dos policiais militares, que realizou o acompanhamento, que o acusado Charles, ao buscar o telhado de um outro imóvel, jogou uma sacola, em cujo interior havia porções de cocaína, como se constatou posteriormente. Com auxílio de equipe de apoio, que fora solicitada, conseguiram deter os acusados. Em seguida, em busca realizada no imóvel onde eles inicialmente tinham ingressado, na parte frontal, em uma garagem, encontraram uma garrucha, várias outras porções de cocaína, crack, balança, microtubos vazios, comumente utilizados no embalagem da cocaína, dinheiro e também um copo de liquidificador, contendo igualmente cocaína, ambos posteriormente admitindo a prática do comércio ilícito.

Como se tem consagrado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento dos policiais militares envolvidos nas diligências. A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54). Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função

salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu). Para além da idoneidade de que gozam os depoimentos dos policiais militares que realizaram a apreensão do entorpecente, não se mostra crível que tivessem iniciado a diligência sem qualquer motivação anterior, escolhendo aleatoriamente o imóvel onde os acusados disseram se encontrar, a reparar uma torneira. Ademais, não apenas se apreendeu quantidade de substância entorpecente significativa e variada, como também petrechos relacionados ao preparo e embalagem da droga, o que evidentemente afasta a alegação de que os policiais estariam a incriminar indevidamente os acusados, os quais, ademais, ostentam envolvimento anterior com o comércio ilícito de entorpecentes.

E também em função da apreensão de entorpecentes de naturezas diversas, em quantidade significativa, acompanhados de petrechos destinados ao preparo e embalagem, dúvida igualmente não há sobre a destinação mercantil.

Deste modo, as provas produzidas permitem seguro juízo de convicção da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Entretanto, já agora, após o desenvolvimento de atividade cognitiva mais aprofundada, remanesce dúvida sobre a imputação da prática do delito previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03.

É que se extrai da prova produzida tratar-se de uma arma já antiga (garrucha), inclusive parcialmente operante, com indicação de que se encontrava no imóvel e que este estava desabitado, anteriormente ocupado por familiar antigo dos acusados, a quem atribuíram a propriedade. Dessa forma, diante destas circunstâncias, não se pode afastar a possibilidade de que aquele armamento efetivamente não estava sendo possuído pelos acusados, ensejando, como dito, dúvida razoável sobre a imputação inicial neste ponto, sendo de rigor o reconhecimento do non liquet.

Isto considerado, passo à dosagem das penas.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, e considerando ainda que a quantidade e a diversidade do entorpecente apreendidos serão considerados posteriormente, a evitar bis in idem, devem as penas-bases ser fixadas no mínimo legal para ambos os acusados, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A pena-base cominada ao acusado Charles Marques deve ser agravada em 1/6 (um sexto), por conta da recidiva (fls. 135), totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Deixo de reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Não apenas em função da recidiva específica do acusado Charles Marques, mas também diante das circunstâncias acima indicadas, de apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecente, além de petrechos utilizados no preparo e embalagem da droga, revelam inequívoca dedicação à atividade criminosa, não se tratando os acusados -- que inclusive ostentam registro de envolvimento anterior com a prática deste delito--, "neófitos" que fizessem jus ao chamado "tráfico privilegiado".

O valor das pecuniárias fica fixado no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória e, em consequência:

(i) com fundamento no artigo 33, caput, Lei nº 11.343/06, c.c.artigo 61, I, do Código Penal, CONDENO o acusado CHARLES MARQUES DIONÍSIO à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, diante da situação econômica do acusado, corrigido desde a época do fato;

(ii) com fundamento no artigo 33, caput, Lei nº 11.343/06, CONDENO o acusado ODAIR APARECIDA PAVAN JÚNIOR à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, diante da situação econômica

do acusado, corrigido desde a época do fato; e,
(iii) com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO os acusados da imputação prevista no artigo 12, da Lei nº 10.826/03. Sobre o regime inicial de cumprimento da pena, e considerando a natureza hedionda do delito, por equiparação, atendendo comando constitucional (art. 5º, XLIII, CF), dispõe o artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, que deve a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, introduzindo a progressividade, a fim de sanar vício da redação inicial que determinava o integral cumprimento da sanção em regime prisional fechado, o que atentaria contra o princípio da individualização da pena.

Não se ignora que, ainda esta alteração, com disposição de início em regime fechado, foi também considerada inconstitucional, em caráter incidenter tantum, no HC nº 111.464/ES, sendo Relator o Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, entendendo-se padecer do mesmo vício de violação ao princípio da individualização da pena, devendo ser fixado o regime prisional, mesmo em se tratando de delitos hediondos e equiparados, na forma do artigo 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

Nada obstante a autoridade da mencionada decisão, proferida pelo Pretório Excelso, em controle difuso, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade, e considerando a controvérsia que marca a questão, até mesmo no âmbito da Suprema Corte, já que a decisão foi tomada por maioria de votos, possível dizer, com a mais elevada vênua, que em função do comando previsto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, cuidou o legislador infraconstitucional em estabelecer tratamento mais rigoroso para o cumprimento da pena de alguns delitos (hediondos e equiparados) dada a maior gravidade da violação aos bens juridicamente protegidos, por isto se estabelecendo no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a alteração dada pela Lei nº 11.464/07, que a pena seria cumprida em regime prisional inicial fechado.

Não se entende, renovada a vênua, tenha a disposição legal violado o princípio da individualização da pena, porquanto, não obstante a limitação ao regime inicial mais gravoso, como ocorre em situações outras, dada a valoração legitimamente exercida pela atividade legislativa, tendo como fonte o anseio de se reprovar de forma distinta ações delitivas que causam maior perturbação ao meio social, não se tem por interditada a progressividade no cumprimento da pena, tampouco os benefícios do livramento condicional e a remissão, o que assegura a individualização da sanção, sem descurar de suas funções retributivas e preventivas, além de ressocializadoras.

Como se tem objetado, se o regime inicial obrigatoriamente fechado é inconstitucional, por conta de critérios qualitativos (crimes hediondos e equiparados), também o seria pelo critério quantitativo da regra prevista no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, que prevê obrigatoriamente regime prisional inicial fechado no caso de pena superior a 8 (oito) anos.

Além disto, submetendo a individualização da pena em casos de delito hediondo ou equiparado tão somente às regras gerais previstas no artigo 33, §2º, do Código Penal, estar-se-ia retirando eficácia do comando inserto na Constituição Federal que determinou a adoção de tratamento diferenciado mais rigoroso nestas hipóteses (cf. art. 5º, LXIII, CF).

Deste modo, a pena cominada aos acusados deverá ser inicialmente cumprida em regime prisional fechado, isto também decorrendo da recidiva ostentada pelo acusado Charles Marques, não se lhe facultando a interposição de recurso em liberdade, já que persistem os fundamentos que determinaram a prisão cautelar, potencializados pela sentença condenatória, sem prejuízo de eventual progressão em sede de execução provisória. Sobre isto: “O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência (Súmula nº 9, do STJ)” (HC nº 86907/RS, Rel. Min. Felix Fisher, DJU. 14.04.2008, p.1).

E, especificamente aqui, “a apelação em liberdade prevista no art.59 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a cumulação dos pressupostos da primariedade e da inexistência

de antecedentes com o fato de ter o réu respondido em liberdade a ação penal, tanto pela inocorrência de prisão oriunda de flagrante delito quanto pela inexistência de decreto de prisão preventiva" (HC - Agr. 94.521/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 1º.08.2008).

E, por fim: "o agente que responde a todo o processo por tráfico ilícito de entorpecente preso não tem o direito de aguardar o recurso interposto pelo Órgão Ministerial em liberdade, mesmo tendo a sentença contra si prolatada substituído a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e serviços à comunidade, eis que a efetividade imediata da pena substitutiva, configuraria em execução provisória" (TJSP, HC 387.079-3/4, 5ª Câmara, Rel. Des. Gomes de Amorim, v.u., RT807/605, apud RENATO Marcão, Tóxicos, 4ª ed.p.527).

E diante do quantum da pena aplicada, não incide as disposições previstas no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Por fim, em relação ao acusado Odair Aparecido, que respondeu solto ao processo, não sendo reincidente, faculto a interposição de recurso em liberdade.

Recomende-se o acusado Charles Marques Dionísio na prisão em que se encontra e, oportunamente, promova-se o registro das condenações definitivas no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA